

1501825-86.2021.8.26.0318

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FELIPE CAVASSO

Comarca: Leme

Foro: Foro de Leme

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/08/2022

... como ambos estariam praticando o tráfico de drogas.

Interrogado, Fernando admitiu a prática do tráfico, mas disse que não conhecia

Bruno, o qual não está envolvido na prática delituosa.

Bruno negou a prática delituosa. Disse que conhece Fernando porque são vizinhos.

Residem há bastante tempo ali. Sentou em frente à sua casa e quando Fernando chegou para entrar na casa de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Leme

Foro de Leme

Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos 770, Leme-SP - cep 13610-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501825-86.2021.8.26.0318 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501825-86.2021.8.26.0318

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2301009/2021 - DEL.POL.LEME, 21210611 - DEL.POL.LEME, 6071/21/807 - DEL.POL.LEME, 2301009 - DEL.POL.LEME

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDO APARECIDO BRANDÃO DA SILVA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz Substituto: FELIPE CAVASSO

BRUNO LOPES DO NASCIMENTO e FERNANDO APARECIDO BRANDÃO DA SILVA foi(ram) denunciado(a)(s) como incurso(a)(s) no artigo 33, "caput", e no artigo 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, na forma do artigo 69, "caput", do Código Penal, porque, segundo a denúncia no dia 04 de novembro de 2021, por volta das 18h00, na Rua Salvador do Nascimento, nº 157, Conjunto Habitacional Fernando Marchi, nesta cidade e comarca de Leme/SP, em concurso de agentes e unidade de desígnios, traziam consigo e guardavam, para fins de tráfico, 364 invólucros plásticos de cocaína, pesando aproximadamente 405 gramas (cf. Auto de Exibição e Apreensão de fls. 17/18 e Auto de Constatação Preliminar de fls. 25/26), substância que é entorpecente e que determina a dependência física e psíquica do agente, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O(a)(s) acusado(a)(s) foram notificado(a)(s) e apresentaram defesa prévia. A denúncia foi recebida, não sendo absolvidos sumariamente e inaugurando-se a instrução criminal, ao longo da qual ouviram-se as testemunhas, interrogando-se os acusados ao final.

As partes manifestaram-se em debates, pugnando o Ministério Público pela condenação, e a(s) Defesa(s) requereram a absolvição ou aplicação da pena em seu patamar mínimo, com os consectários legais.

É o relatório. Fundamento e decido.

Procede em parte a pretensão punitiva.

A materialidade está comprovada pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 145/147).

A autoria é certa.

O policial militar Claudinei Aparecido Vantin disse que ele e seus parceiros de farda já tinham conhecimento de que no local dos fatos os réus estariam realizando a venda de entorpecentes. As informações davam conta de que Fernando faria a venda das drogas até as 18h00 e Bruno a partir da 18h00. Essas informações são passadas por moradores locais, que não compactuam com práticas ilícitas, mas têm medo de se apresentar formalmente. Os agentes foram até o local para averiguar as denúncias. Quando chegaram ao local, avistaram os dois indivíduos abaixados mexendo no mato. Quando eles perceberam a aproximação da viatura, saíram correndo, em sentido a residência da genitora de Fernando que fica na mesma rua dos fatos. Antes que pudessem acessar a residência, os agentes conseguiram os abordar. Em busca pessoal com Fernando vieram a localizar 4 eppendorffs com cocaína e a quantia em dinheiro de R\$90,00 (noventa reais) e com Bruno nada de ilícito foi encontrado. Retornaram ao local onde os réus foram vistos e encontraram em meio aos arbustos, uma sacola plástica contendo em seu interior 12 kits, com 30 eppendorffs de cocaína cada, totalizando 360 eppendorffs de cocaína. Posteriormente o réu Fernando confessou que os entorpecentes eram seus e estava realizando a traficância, já Bruno preferiu permanecer em silêncio.

No mesmo sentido, o policial militar Menezes Manoel de Barros, que apontou a existência de denúncias a respeito de ambos os acusados e a forma como ambos estariam praticando o tráfico de drogas.

Interrogado, Fernando admitiu a prática do tráfico, mas disse que não conhecia Bruno, o qual não está envolvido na prática delituosa.

Bruno negou a prática delituosa. Disse que conhece Fernando porque são vizinhos. Residem há bastante tempo ali. Sentou em frente à sua casa e quando Fernando chegou para entrar na casa de sua mãe, os policiais o abordaram. Não estava abaixado com Fernando. Está com 26 anos atualmente. Na época da sua prisão, trabalhava no depósito de gás do seu pai. Somente não estava trabalhando no dia da prisão porque foi a uma loja com sua mãe e seu pai o dispensou do trabalho.

Não há dúvida a respeito da traficância por parte de ambos os réus, observando-se a incidência do artigo 29 do Código Penal.

Isso porque, os policiais militares ouvidos em audiência prestaram relatos harmônicos e coerentes a respeito da existência de denúncia sobre a prática do tráfico por parte de ambos os acusados, que se revezariam no comércio de drogas no local em que se deu a apreensão.

Os milicianos foram expressos ao apontar que viram os dois réus abaixados no local onde foi apreendida quantidade expressiva de entorpecentes (mais de 300 eppendorfs), sendo certo que se tratava de local muito conhecido nesta cidade como ponto de venda de entorpecentes.

É certo que, se comparados os depoimentos prestados em sede inquisitiva e judicial, sempre será possível verificar a existência de pequenas contradições, que se reputam naturais, porque a ninguém é dado prestar depoimentos estritamente idênticos, sem nenhuma diferença.

O que importa, no entanto, é a coerência no que é fundamental.

No caso, fundamental era a quantidade da droga, sua forma de acondicionamento, com quem foi encontrada e em que circunstâncias isso se deu. Cumpre consignar que nada há nos autos que indique intenção das testemunhas em incriminar indevidamente o acusado.

Além disso, acolher essa tese seria desmerecer o trabalho dos policiais em suas investigações.

Salvo comprovação em contrário, a atuação dos agentes públicos goza de presunção de veracidade e legitimidade. Sobre o tema, invoco famoso precedente da lavra do eminente Min. Celso de Mello: Prova – Depoimento testemunhal de agentes policiais – Validade. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos (STF, 1ª T., HC nº 74.608-0/SP).

De outro lado, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, para determinar se a droga destinava-se ao consumo pessoal ou de terceiros, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Nessa medida, apreendeu-se significativa quantidade de droga, qual seja, mais de 300 porções de cocaína, acondicionadas de maneira usual para o fornecimento a terceiros.

Ademais, há que se considerar que os réus foram detidos em local conhecido da polícia como ponto de tráfico de entorpecentes, observando-se a existência de denúncias e informações prévias, de aproximadamente 30 dias, no sentido de que os dois réus seriam responsáveis pelo tráfico no local.

As versões de ambos os réus, constante de seus interrogatórios, foram desencontradas, porquanto embora Fernando tenha sido categórico ao afirmar para este magistrado que desconhecia a pessoa do corréu Bruno, este, por sua vez, desmentiu a história ao relatar que ambos são conhecidos de longa data, porque residem em casas vizinhas.

Assim, retira-se a credibilidade da versão exculpatória prestada por Fernando em benefício de Bruno, circunstância que, dentro do conjunto probatório, dá mais robustez aos depoimentos coerentes prestados pelos agentes públicos, o que deve considerado na valoração da prova.

Contudo, afasta-se o crime de associação criminosa previsto no artigo 35, da Lei nº 11.343/06, pois em momento algum foi evidenciado o animus associativo, relativo à finalidade de praticar, reiteradamente, o crime mencionado no artigo 33, caput, da mesma Lei, tampouco a permanência na *societas criminis*, a qual não se confunde com a mera coautoria.

Não há nos autos investigações, prévias ou posteriores à prisão em flagrante dos acusados, aptas o bastante a comprovar o propósito associativo entre ambos, podendo-se dizer, diante do conjunto probatório, que inexistiu o propósito associativo entre os acusados, visando à prática do crime de tráfico de entorpecentes, o que demonstra hipótese de configuração de concurso de pessoas e não de crime autônomo.

Acrescento o entendimento dos Tribunais:

O crime consuma-se com a simples associação previamente organizada, de caráter estável e permanente, independentemente de qualquer outro fato que venha a ser cometido pelos agentes. Desde que a associação delituosa, já caracterizada, alcança seu fim consistente na prática de crimes, lesa nova objetividade jurídica, possibilitando o concurso de delitos (STJ, REsp 3.943/SP, 5ª T., rel. Min. Flaquer Scartezini, . 26-9-1990, DJ 5-11-1990, JSTJ 20/45).

O delito previsto no art. 35, da nova lei, pressupõe, para o seu reconhecimento, a demonstração do dolo de associar-se de forma estável. É necessário que se identifique, na *societas criminis*, o caráter permanente, que não se confunde com a mera coautoria (TJMG – Ap. Crim. 1.0145.08.435450-8/001, 5ª Câmara Crim., rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, j. 24/03/2009).

É possível que os acusados tenham cometido tal crime, no entanto, as provas amealhadas aos autos não são suficientes para um decreto condenatório. Reconhecida a ação criminosa, passo à fixação da pena (sistema trifásico: art. 68, caput, do CP).

Réu Fernando Aparecido Brandão da Silva

Primeira fase: sopesadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, de natureza subjetiva (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do agente) e objetiva (motivos, circunstâncias e consequências do crime), com a preponderância do artigo 42 da Lei de Drogas, observa-se que Fernando possui maus antecedentes, na medida em que ostenta duas condenações definitivas anteriores (certidão de fls. 231/234). Ambas as condenações são por tráfico de entorpecentes, o que demonstra personalidade do réu voltada à prática de crimes dessa natureza. Outrossim, foi expressiva a quantidade de droga apreendida, mais de três centenas de eppendorfs. Por essas circunstâncias, fixo a pena-base em um quinto acima do mínimo legal, 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Segunda fase (arts. 61, 62 e 65, CP): compensa-se a agravante da reincidência com a confissão espontânea havida em audiência.

É este o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, firmado em sede de recurso repetitivo (tema 585), cuja tese é a seguinte: É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

Anote-se, por ser oportuno que o relator do TEMA 585/STJ proferiu decisão no REsp 1.738.994/PA (DJE 06/08/2018), integrante da controvérsia n. 53, decidindo:

"Outrossim, recentemente, em 11/10/2017, a Terceira Seção, no julgamento do Habeas Corpus n. 365.963/SP, firmou a jurisprudência no sentido que a especificidade da reincidência não obstaculiza sua compensação com a atenuante da confissão espontânea. Ou seja, a reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. Todavia, tratando-se de réu multirreincidente, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade".

Portanto, nesta etapa, a pena permanece inalterada.

Terceira fase: Não se reconhece a incidência do disposto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, porque o réu não é primário.

Pena definitiva: 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

O dia multa é fixado no mínimo legal, considerando-se a condição econômica do acusado.

Regime inicial de cumprimento (art. 33, §§ 2º e 3º c/c art. 59, III, CP, e art. 387, § 2º, CPP): será inicialmente o fechado, porque as circunstâncias judiciais são desfavoráveis, e este acusado ostenta maus antecedentes e ainda é reincidente específico, de modo que regime mais brando não faria atender às finalidades de reprovação pela conduta praticada.

Substituição por penas alternativas (art. 44, CP): inviável, pelos mesmos fundamentos elencados.

Réu Bruno Lopes do Nascimento

Primeira fase: sopesadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, de natureza subjetiva (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do agente) e objetiva (motivos, circunstâncias e consequências do crime), com a preponderância do artigo 42 da Lei de Drogas, observa-se que o réu é primário (fl. 225), inexistindo elementos aptos a justificar a elevação da pena-base para ele. Fixo-a no mínimo legal, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Anote-se que a quantidade da droga será levada em consideração na terceira fase de aplicação da pena, para evitar bis in idem.

Nesse sentido: A controvérsia destes autos foi pacificada pelo Supremo Tribunal

Federal em recente julgado realizado pelo Plenário, ocorrido em 19/12/2013, na análise dos HC 112.776/MS e HC 109.193/MS, ambos de relatoria do Min. Teori Zavascki. Naquela oportunidade, esta Corte firmou o entendimento de que as circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas apreendidas em poder de um réu condenado por tráfico de entorpecentes apenas podem ser utilizadas, na primeira ou na terceira fase da dosimetria da pena, sempre de forma não cumulativa. Ressaltou-se, que a utilização em duas fases do cálculo da pena caracteriza o bis in idem, bem como autorizou a análise monocrática dos pedidos de habeas corpus que tratem sobre o tema. Desse modo, cabe ao juiz sentenciante, de acordo com seu poder discricionário, definir em qual momento da dosimetria da pena a circunstância referente a quantidade e a natureza da droga será utilizada, desde que não seja de maneira cumulativa para evitar-se a ocorrência de bis in idem (STF - RHC/MC nº 122.496/RS, Relator: Min. Luiz Fux. Data de julgamento: 22/08/2014 - grifos meus). Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas, observando-se ainda súmula 231 do STJ: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Na terceira fase, reconhece-se, para o réu Bruno, a incidência do disposto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, porque o réu é primário, não ostenta maus antecedentes, não está comprovado que se dedicava à atividade criminosa, tampouco que integrava organização criminosa.

Não se desconhece que a quantidade de droga apreendida poderia ser indicativo de que o acusado se dedicava à atividade criminosa. No entanto, é preciso considerar que ele foi detido em conjunto com o corréu Fernando, pessoa que se dedica à traficância nesta cidade, conforme ficou bem provado nesta ação penal e nas condenações anteriores deste corréu.

Entretanto, Bruno é primário e consta que possuía ocupação lícita à época dos fatos, inexistindo maiores elementos aptos a indicar que ele se dedicava, de forma reiterada, à prática do tráfico. O cenário dos autos mais se aproxima de um auxílio ocasional a Fernando, o que não pode impedir o reconhecimento do tráfico privilegiado em benefício de Bruno, porquanto em relação a ele parece bem mais provável se tratar de traficância ocasional.

Em razão da quantidade de droga apreendida, uma vez reconhecida a causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, reduzo a pena de metade, chegando-se a 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

O regime de cumprimento da pena será o aberto porque, nos termos do entendimento adotado pelo colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus n. 118-533/MS, não se aplicam ao tráfico minorado as regras particulares destinadas aos crimes hediondos, o que impõe tratamento benéfico e diferenciado ao indivíduo que comete este crime de forma episódica.

Ainda, presentes os requisitos legais, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Em razão do reconhecimento da possibilidade de aplicação da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006), da aplicação do regime aberto para cumprimento da pena e da substituição da privativa de liberdade por restritivas de direito, impõe-se a revogação da prisão preventiva do réu Bruno, uma vez que não subsistem os motivos que ensejaram sua decretação, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal.

Por fim, o réu Fernando deverá permanecer na prisão, para a garantia da ordem pública, ante a natureza do delito e à vista de todo o exposto, especialmente das considerações quanto à fixação do regime fechado para início de cumprimento da pena, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, notadamente neste momento, com prolação de sentença condenatória, mantidos os demais fundamentos que embasaram a decretação da prisão cautelar.

Ante o exposto, julgo procedente em parte a ação penal e:

- (i) absolvo FERNANDO APARECIDO BRANDÃO DA SILVA e BRUNO LOPES DO NASCIMENTO, qualificados nos autos, da prática do crime previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;
- (ii) condeno FERNANDO APARECIDO BRANDÃO DA SILVA, qualificado nos autos, como

incurso(a)(s) no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, no piso legal mínimo;

(iii) condeno BRUNO LOPES DO NASCIMENTO, qualificado nos autos, como incurso(a)(s) no art. 33, caput, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no piso legal mínimo. Substituo a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, que deverá ser fixada no juízo das execuções, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, conforme regramento do artigo 46 e §§, do Código Penal, e pagamento de prestação pecuniária, no valor um salário mínimo, a ser revertida a instituição de caridade oportunamente indicada.

Tendo o réu Fernando respondido ao processo em prisão cautelar, e como não houve alteração no panorama probatório que ensejou tal fato - aliás, a sentença reconheceu a responsabilidade criminal -, denega-se o direito de recorrer(em) em liberdade, subsistentes os pressupostos e os requisitos da prisão preventiva (art. 312 c/c art. 313, CPP) nos termos do que foi decidido anteriormente neste processo. Recomende-se na prisão em que se encontra.

Revogo a prisão preventiva do réu Bruno. Expeça-se alvará de soltura.

Decreto o perdimento dos bens e valores apreendidos, em favor da União, com posterior reversão ao Funad, após o trânsito em julgado, na forma do artigo 63 e §§ da Lei nº 11.343/2006.

Fica também autorizada a incineração do entorpecente, caso ainda não procedida.

Os acusados pagarão a taxa judiciária, ressalvado o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, aplicado por analogia, em razão de sua hipossuficiência e da gratuidade.

Após o trânsito em julgado: a) Comunique-se o Instituto de Identificação (IIRGD); b) oficie-se ao TRE para cumprimento do disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição da República de 1988; c) expeça-se guia de execução definitiva ou oficie-se para aditamento da guia de recolhimento provisória, remetendo-se ao juízo competente; d) intime-se o réu para pagamento da multa, no prazo de 10 (dez) dias e da taxa judiciária, se o caso, em 60 (sessenta) dias, procedendo-se na forma dos artigos 480 e 480-A das NSCGJ.

Arbitro honorários ao(à) douto(a) advogado(a) dativo(a) no máximo da tabela (Convênio DPE/OAB-SP), expedindo-se certidão com o trânsito em julgado.

Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se.

Publique-se e intuem-se.

Leme, 16 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA